

1500820-90.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500820-90.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214033/2022 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 26603390 -

DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2214033 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DE OLIVEIRA BATISTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

ANDERSON DE OLIVEIRA BATISTA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, e do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, porque no dia 07 de agosto de 2022, na Rodovia BR 381, Km 07, cidade de Vargem, nesta Comarca, visando alcançar o Estado de Minas Gerais, transportava, para consumo de terceiros, 798 tijolos de maconha, pesando

aproximadamente 640 quilos, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, conduziu veículo automotor (caminhão), em via pública, estando com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina dependência.

Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 112/115. Recebida a denúncia aos 29 de agosto de 2022 (fl. 130), o feito seguiu o seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas de acusação e duas da defesa. Ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fls. 182).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 203/212 e 276/277).

A defesa pugnou, preliminarmente, pela inépcia da denúncia. No mérito postulou pela absolvição embasada na ausência de provas da autoria, a par da fragilidade dos depoimentos colhidos, sustentando, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada (fls. 251/266).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, não prospera a alegação da defesa nessa seara.

A inicial narrou adequadamente o fato típico e preencheu todos os requisitos legais, possibilitando ao acusado toda defesa possível. Assim, havendo a descrição correta dos fatos imputados há elementos para prosseguimento da ação.

No mérito, a materialidade do delito de tráfico está plenamente comprovada.

O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 135/137) descreveu e concluiu que a substância analisada é maconha, caracterizada por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos colhidos a autoria também se evidenciou, não obstante as escusas inconvincentes do acusado, que em seu interrogatório negou a prática da infração. Anderson disse que num determinado dia, enquanto estava num posto de gasolina, uma pessoa desconhecida o contratou para conduzir um caminhão até determinado local. Em contraprestação, lhe daria uma porção de droga. Mencionou que havia ingerido bebida alcoólica e consumido drogas. Durante o trajeto, foi abordado por policiais rodoviários que, após vistoria ao veículo, localizaram a droga no interior do caminhão que ele conduzia. Ao final, argumentou que não sabia que transportava o entorpecente.

Sua escusa não convenceu e restou isolada nos autos.

Primeiro porque Anderson sequer identificou a pessoa que supostamente teria lhe contratado para a condução do caminhão. Nenhuma prova fez nesse sentido, ônus que lhe incumbia.

Ao depois, durante a etapa policial ele se calou:

“Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo”.

Ora, se de fato Anderson desconhecesse a ilicitude do material apreendido na ocasião de sua prisão, certamente teria declarado tal situação durante seu interrogatório extrajudicial. Somente em Juízo ele apresentou tal versão.

Desta forma, desacreditadas suas palavras, em especial diante do acervo que se reproduzirá adiante.

Em brilhante decisão, da lavra do Des. José Raul Gavião de Almeida, que tomamos da liberdade de reproduzir, o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou que a versão do acusado, quando esposada, deve ser comprovada para merecer confiabilidade.

“A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (“o preso

será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta.

Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se.

Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade.

Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito à valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa.

Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da autodefesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional.

Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor.

É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade”.

Frise-se, por oportuno, que durante a diligência policial foi apreendida expressiva quantidade de droga, aproximadamente 640 quilos de maconha. Destarte, a circunstância de encontrar-se o acusado na posse dessa quantidade de droga, configura, por si só, a plena demonstração do animus de traficar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos dos guardas municipais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno traficante, não se pode cogitar da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como da fixação de regime inicial diverso do fechado. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, porém, sem repercussão na pena final. (TJSP; Apelação 0002855-33.2017.8.26.0526; Relator (a): Luís Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. Absolvição por falta de provas para o crime de tráfico - inocorrência - materialidade e autoria delitivas comprovadas - apreensão de variedade e expressiva quantidade de drogas na residência do recorrente, bem como a arma de fogo - circunstâncias da prisão do recorrente que atestam a prática de tráfico. Penas aplicadas de forma motivada, dentro dos parâmetros legais. Regime fechado é o correto diante da gravidade concreta dos crimes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0001123-48.2017.8.26.0548; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018)

No mais, ele se escusou da imputação por meio de simples negatória geral, sem indicar por quais motivos poderiam os policiais querer lhe imputar

injustificadamente crime de tamanha gravidade.

Se não bastasse a força de convencimento ínsita nos argumentos expostos, corroboram a certeza da autoria os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução.

Senão vejamos.

O Policial Rodoviário Salomão relatou que naquele dia realizava patrulhamento de rotina pela Rodovia Fernão Dias quando avistou um veículo caminhão trafegando com luzes traseiras apagadas, como ainda, seu condutor estava ziguezagueando pela via, razão pela qual resolveu abordá-lo.

Durante a abordagem, observou que o condutor do veículo estava visivelmente embriagado e se mostrou confuso quanto às perguntas que lhe foram feitas. Realizada revista no veículo, observou que na parte debaixo do chassi havia um compartimento e, ao abri-lo, localizou grande quantidade de drogas. Diante disso, indagou-o sobre os fatos, oportunidade em que o acusado admitiu que havia pego o veículo num posto de gasolina na cidade de São Paulo e que o conduziria até a cidade de Caxambu, no Estado de Minas Gerais.

Eis suas palavras:

D: "O condutor do caminhão até hesitou em parar, mas aí a gente já ligou o sinal sonoro da viatura da polícia, aí ele parou. A gente pediu pra ele descer do caminhão. Ele desceu. Ele não sabia da onde que, no momento ele não sabia da onde que estava vindo, pra onde que estava indo. Não tinha a CNH em mão. Nem documento do caminhão. E pra nós ali, realmente ele estava visivelmente, visivelmente alterado né? Agitado. Então diante dessa suspeição a gente foi revistar o caminhão, foi revistar o caminhão, na caçamba, era uma carroceria, em cima realmente não tinha nada, só tinha nada ali, mas em duas camadas aprofundadas a gente viu que entre a carroceria e a parte debaixo do chassi, tinha um compartimento né? E esse compartimento ali, nesse tipo de caminhão não existe né? Foi feito um compartimento, e a gente abriu uma das tábuas ali em cima e pode observar vários tabletes de maconha. Aí a gente já viu, algemamos ele e levamos pra delegacia. Aí diante da medida ali a gente perguntou naquele momento lá se ele tinha utilizado alguma droga, e ele falou que tinha utilizado cocaína e que era viciado".

Suas versão é confirmada pelo Policial Rodoviário Júlio Cezar, que de forma séria e coerente narrou a abordagem realizada ao acusado, bem como a suspeita que o levou a revistá-lo. Ainda, certificou o encontro das drogas em um compartimento oculto do caminhão conduzido pelo acusado.

Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão do acusado tivesse qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade do agente. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento

policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Repise-se, assim, que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e uníssonos. Frise-se também que ambos agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, o ocorrido naquela ocasião, inclusive com riquezas de detalhes demonstrando toda a operação realizada, a abordagem policial e revista ao agente, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos.

Nessa esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROCESSO PENAL - PROVA -DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - IDONEIDADE -RECONHECIMENTO. É idônea a prova testemunhai colhida, constituída do depoimento dos policiais que efetuaram a diligência. (TJ-SP - APL: 993061147033 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/05/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2010)

APELAÇÃO. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito têm natureza de "crimes permanentes", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada no interior de uma residência. Precedentes do STF. 2. As autorias e as materialidades dos crimes de tráfico de drogas e roubos, um majorado e outro simples, restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na casa do réu e os objetos roubados encontrados em sua posse. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. 12. O instituto da detração, para ser aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das Execuções Penais é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. 13. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00628017920128260050 SP 0062801-79.2012.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática,

reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014) As testemunhas de defesa ouvidas não foram capazes de descaracterizar as provas orais colhidas. Sérgio e Cirlene não presenciaram os fatos e apenas prestaram relatos atestando a conduta social do acusado.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, o local e as circunstâncias como foi surpreendido, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenha o agente efetuado a venda. Basta que a possua ou tenha em depósito com o fim de colocá-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclitación do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afinal, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, verbi gratia, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

A conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente às figuras "guardar, ter em depósito e transportar", previstas no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, imprescindível que a defesa comprovasse a ausência de consciência da ilicitude da conduta, não sendo suficiente meras alegações do acusado acerca do desconhecimento da existência da droga.

Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS - Acusado que foi surpreendido por policiais militares em via pública, na condução de veículo automotor, transportando 91 "tijolos" de maconha (peso total de 60,5 kg) - Magistrada de Primeiro Grau que absolveu o agente, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal - Ministério Público que recorre, requerendo condenação nos termos da denúncia. TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo (maconha) - comprovação que o material apreendido é droga. TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA - depoimentos de policiais militares que confirmam a apreensão de drogas (91 "tijolos" de maconha, com peso de 60,5kg) - Validade - Depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela - de rigor a condenação do réu. TRÁFICO - destinação a terceiros - sentenciado que foi surpreendido transportando expressiva quantidade de maconha (91 "tijolos" de maconha, com peso de 60,5kg). PENA - Primeira fase - Pena-base fixada em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, com base no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 - Segunda fase - Sem alteração - Terceira fase - Sem alteração, visto não ser possível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas uma vez que o acusado se dedicava a atividade criminosa. REGIME - Fechado - único regime que se mostra necessário para afastar o réu da senda criminosa - Beccaria. Recurso ministerial que comporta provimento. (TJ-SP - APR: 15197760920208260228 SP 1519776-09.2020.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 09/03/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Provas suficientes à condenação - Réu preso em flagrante - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de expressiva quantidade de crack - Erro de tipo - Inadmissibilidade - Réu que tinha ciência que transportava droga para entrega a terceiro - Alegação inverossímil quanto ao desconhecimento do conteúdo da encomenda - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Pena-base fixada no mínimo legal - Incidência da circunstância atenuante da menoridade, sem reflexo na pena, a teor da Súmula nº 231, do STJ - Réu beneficiado com a aplicação do redutor máximo previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade da fixação de regime diverso do fechado e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Regime fechado compatível com a conduta praticada pelo réu - Determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do réu, após o decurso do prazo para oposição de eventual embargos de declaração - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 00087433620148260510 SP 0008743-36.2014.8.26.0510, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 27/04/2017, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/05/2017)

Destarte, bem comprovadas a autoria e materialidade da infração, ficando sem guarida as combativas alegações da defesa.

Prosseguindo, a ação também procede quanto ao crime previsto no artigo 306, do CTB. A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas.

A atual redação do dispositivo, uma vez suprimido o elemento normativo 'expondo a dano potencial a incolumidade de outrem', transmudou o caráter do perigo para configuração do ilícito.

Dispensou-se o risco concreto, a ser comprovado faticamente (em regra, por testemunhas), mas se presumiu em absoluto que um motorista, ao ingerir determinada quantidade de álcool, representa uma insegurança nas vias públicas. Ele é considerado um inimigo da segurança viária.

Bastam, portanto, para a configuração da infração a existência de dano potencial para a coletividade - contentando-se a legislação com a mera conduta para a caracterização de um crime de perigo abstrato - , e umas das formas da materialidade previstas no § 10, na espécie, o inciso II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Na espécie, a prova é segura em confirmar a imputação inicial.

O acusado durante seu interrogatório em Juízo admitiu que conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica e consumir drogas.

Sua confissão está em harmonia com as demais provas.

Os policiais rodoviários narraram que somente abordaram o acusado porque ele conduzia o veículo de forma irregular, ziguezagueando pela rodovia. Salientaram que durante a diligência policial, observaram que ele apresentava sinais de embriaguez, como fala pastosa e desequilíbrio, além de estar bem alterado.

Desta forma, tudo nos leva a crer que o acusado agiu de forma imprudente, colocando em risco sua segurança e da comunidade.

Assim sendo, a conduta do acusado subsumiu-se ao tipo legal denunciado, pois ele dirigiu veículo automotor em estado de embriaguez.

Ressalte-se que, embora não tenha sido realizado exame toxicológico, o § 2º, do artigo 306, dispõe que a verificação da alteração da capacidade psicomotora poderá ser obtida mediante prova testemunhal.

Na espécie, as testemunhas ouvidas comprovam que o acusado dirigiu veículo automotor estando com sua capacidade psicomotora alterada.

O crime de embriaguez é de perigo abstrato, prescindindo, portanto, de resultado lesivo. Sua objetividade jurídica é a incolumidade pública, eis que a condução de veículo nestas condições coloca em sério risco a coletividade.

Vale lembrar que o delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pressupõe para sua configuração apenas a condução de veículo, em via pública, sob a influência do álcool, reduzindo o nível de segurança do trânsito, exigido pelo legislador, não sendo necessária ocorrência do perigo concreto.

Nessa esteira:

Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP. "Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 306. Embriaguez ao volante. A integração do tipo legal do crime de embriaguez ao volante, requisita-se, somente o dano potencial à incolumidade pública de outrem, situação que não se confunde com exigência de perigo concreto, ou seja, que da conduta resulte em alguma ofensa ao bem jurídico tutelado. O motorista sob a influência alcoólica não tem o domínio do veículo, porque a bebida alcoólica exerce forte depressão sobre o sistema nervoso central, interferindo na sua atenção, na memorização e na capacidade de agir prontamente, expondo, a perigo de dano o bem jurídico incolumidade pública". (AP 1.273.905-4 Rei. Desembargador Márcio Bártoli). A melhor doutrina igualmente pensa nesta direção: "Dirigir embriagado, de maneira anormal, por si só, é uma conduta perigosa. Se se tratasse de crime de perigo concreto, caberia à acusação provar duas vezes o perigo: uma, na demonstração da realização da conduta; outra, na do perigo concreto. Como diz Rui Stocco, 'o ato de dirigir embriagado subentende o perigo de dano, não cabendo exigir sua comprovação, pena de, em casos tais, imperar a impunidade'" (Damásio E. de Jesus - "Código de Trânsito: disposições penais e suas incongruências - Boletim do IBCCrim 61/10). Desta forma, conclui-se que o acusado dirigiu sob a influência de álcool, de maneira imprudente e irregular, colocando em risco a segurança dos transeuntes. Como leciona Damásio E. de Jesus, "expôs qualquer um que passasse pelo local a perigo de dano, daí advindo o perigo concreto indeterminado" (Crime de trânsito, 2ª ed., Saraiva, 1998, p. 161).

Assim, é inquestionável que expôs a incolumidade pública a risco, posto que ela consiste em um número indeterminado de pessoas da comunidade. E na verdade, o perigo é a qualificação do comportamento e não o seu resultado.

O emitente Min. Vicente Cernicchiaro, em acórdão proferido no mês de agosto de 1997, orienta que: "Incolumidade pública significa segurança de todos os cidadãos. Relaciona-se com um número indeterminado de pessoas" (REsp 104.038, 6.ª T., DJU 25.08.1997, p. 39.413).

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade das condutas praticadas pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Ele não ostenta antecedentes criminais e os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros

da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena.

No entanto, levando em consideração as circunstâncias do crime, a par da quantidade do material apreendido, em obediência ao teor do artigo 42, da Lei 11.343/2006, vemos que as penas-base comportam acréscimo por conta deste fator.

Presente a circunstância judicial acima exposta, que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 7 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa no patamar mínimo legal. Quanto ao crime previsto na lei de trânsito, suas penas serão fixadas em seu mínimo legal.

Na segunda etapa, presente a agravante prevista no artigo 289, inciso IV, do CTB, uma vez comprovada que o condenado conduzia o veículo com carteira de habilitação vencida (fls. 159/161), observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual serão compensadas, não havendo outras atenuantes ou agravantes a considerar, especialmente quanto ao crime previsto na lei de drogas.

Na etapa final a causa especial de aumento denunciada deve incidir (artigo 40, inciso V, lei de drogas).

É certo que o condenado transportava o material entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, caracterizando o tráfico entre tais unidades da federação. Assim indicam os depoimentos existentes nos autos, que comprovam que ele estava seguindo rumo ao Estado de Minas Gerais. Logo, as penas serão acrescidas de $1/6$ ($7 \text{ anos} + 1/6 = 8 \text{ anos e } 02 \text{ meses} / 700 + 1/6 = 816 \text{ dias}$).

O acusado é primário, portador de bons antecedentes criminais e, nestes autos, não se demonstrou que ele tenha envolvimento ou integre organização criminosa. Logo, amolda-se na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Assim sendo, suas penas serão diminuídas em $1/6$, pois não existem motivos a justificar maior redução em virtude da quantidade da droga ($8 \text{ anos e } 02 \text{ meses} - 1/6 = 6 \text{ anos, } 09 \text{ meses e } 20 \text{ dias de reclusão} / 816 - 1/6 = 680 \text{ dias}$).

Não obstante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao reconhecimento da desconsideração da hediondez ao tráfico privilegiado, o que possibilitaria o cumprimento inicial de pena em regime mais brando, in casu, ante a quantidade do material apreendido em poder do condenado, aproximadamente 640 quilos de maconha, o regime inicial será o fechado, visto que, qualquer outro regime não contribuiria para a reprovação do crime e ressocialização do agente.

Nessa esteira:

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA – DISCUSSÃO ENVOLVENDO O REGIME PRISIONAL CABÍVEL E A APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS – BENEFÍCIOS INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE – RÉU QUE TRAFICAVA, ALÉM DE MACONHA, TAMBÉM COCAÍNA, DROGA ESTA DE EFEITOS NEFASTOS À SAÚDE DE USUÁRIOS E VICIADOS – NECESSIDADE DE ENÉRGICA REPROVAÇÃO – ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA, QUE JUSTIFICA A RECUSA DOS BENEFÍCIOS, A DESPEITO DA NÃO-HEDIONDEZ DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO. (EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 0100260-13.2015.8.26.0050/50000 Comarca: SÃO PAULO - Processo nº 0100260-13.2015.8.26.0050 Juízo de Origem: 8ª Vara Criminal Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal Embargante: LUCAS SANTANA BATISTA Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME FECHADO. NECESSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Embora não hediondo o crime de tráfico privilegiado, a quantidade e qualidade da droga obstam a fixação do regime mais brando. 3. Negado provimento ao recurso. (APR 10702100791806001 MG Órgão Julgador: Câmaras Criminais Isoladas / 7ª CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 11/01/2013. Julgamento: 13 de Dezembro de 2012. Relator: Marcílio Eustáquio Santos).

Quanto ao crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, ante à primariedade do agente, fixo o regime aberto.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial (regime fechado para o crime contra a saúde pública). Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no

artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução. Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado: Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

O condenado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR ANDERSON DE OLIVEIRA BATISTA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, e do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, respectivamente, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, à pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir por dois meses, e mais 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

Recomende-se na prisão onde ele estiver.

No que se refere ao delito previsto no artigo 306, do CTB, vislumbrando a presença dos pressupostos de aplicação das penas restritivas de direito, nos termos dos artigos 43 e seguintes do Código Penal Brasileiro, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, especificamente pela prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo. Caberá ao Juiz da Execução designar a entidade pública ou privada com destinação social cujo valor recolhido pelo condenado irá beneficiar.

Declaro o perdimento dos bens apreendidos (dinheiro e veículo), derivados do comércio ilícito de drogas, em virtude dos fundamentos utilizados nesta decisão, a teor do artigo 62, da Lei 11.343/2006.

Com o trânsito em julgado, promova as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena, como ainda oficie-se ao Órgão de Trânsito responsável para cumprimento da suspensão imposta.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 02 de dezembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA